Année universitaire 2025-26

PREMIÈRE ANNÉE LICENCE DROIT

INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC

Semestre 1

Cours de Monsieur le Professeur J. Viguier

Dossier n° 6 - La Décentralisation

Travail à réaliser
Sujet de dissertation : La décentralisation remet-elle en cause l'unité de l'Etat ?
Documents
Document 1 : Quelques formules et citations célèbres
Document 2 : P. Esplugas, C. Euzet, S. Mouton, J. Viguier, Droit constitutionnel, 5ème éd., Ellipses
Document 3 : Articles 1er, 72, 72-1 et 72-2 de la Constitution de la Vème République
Document 4 : F. Chaltiel Terral, « Actualité de la notion de décentralisation », Les petites affiches, juin 2012
Document 5 : L. Favoreu, P. Gaïa, R Ghevontian, J-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni, Droit constitutionnel, Dalloz, 19èm édition, 2017
Document 6 : A. Cabanes, P. Sikorav « Décentralisation : place à l'Acte III », Le Monde, 5 fév. 2014
Document 7 : J. Demarthon, « La loi NOTRE pour les collectivités territoriales définitivement adoptée », 16 juillet 2015
Document 8 : M. Verpeaux, « La loi NOTRE dans son contexte », RFDA, juillet-aout, 2016
Document 9 : S. Caporal, P. Esplugas-Labatut, P. Ségur, S. Torcol, Droit constitutionnel, Ellipses, 2017, p.24-25 (**à rechercher à la bibliothèque**)
Document 10 : A. Duranthon, « La subsidiarité et collectivités territoriales », thèse, 2015

Mots clés : décentralisation, déconcentration, clause générale de compétences, autonomie locale, principe de libre administration, contrôle de légalité, principe de subsidiarité

Document n°1 : Formules et citations célèbres

❖ Charles Eisenman, Centralisation et décentralisation. Esquisse d'une théorie générale,1948 :

« Est central un organe qui est investi d'une fonction à l'égard de la collectivité toute entière, c'est-à-dire de tous ses membres indistinctement. Inversement, un organe qui n'est investi d'une fonction qu'à l'égard d'une fraction déterminée de cette collectivité c'est à dire d'une partie seulement de ses membres n'est pas central. » ❖ Maurice Hauriou, Précis de droit administratif, 1919, Préface :

« Les raisons de la décentralisation ne sont point d'ordre administratif, mais bien d'ordre constitutionnel. S'il ne s'agissait que du point de vue administratif, la centralisation (autrement dit la dé- concentration) assurerait au pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intégrée et plus économe que la décentralisation. Mais les pays modernes n'ont pas besoin seulement d'une bonne administration, ils ont besoin aussi de liberté politique. »

❖ Georges Burdeau, Traité de Science politique, 1967, t.2 :

« Le Pouvoir demeure unitaire, c'est son exercice seulement qui est démultiplié par la présence d'un agent qu'il dépêche au point où il y a lieu de décider. Il y a ce que l'on appelle déconcentration. »

« Il apparaît tout de suite que la décentralisation peut, du moins théoriquement, être absolue ou relative. Elle sera absolue lorsque toutes les activités du groupe considéré ne dépendront que de lui ; elle sera relative, si certaines de ses activités seulement sont soustraites à l'emprise d'une autorité extérieure. En fait, comme bien on pense, il n'existe que des cas de décentralisation relative. » ❖ Balzac, Le médecin de campagne :

« Rien n'est plus variable que l'administration : elle a peu de principes généraux. La loi est uniforme, les mœurs, les terres, les intelligences ne le sont pas, or l'administration est l'art d'appliquer les lois sans blesser les intérêts, tout y est donc local. »

❖ Exposé des motifs du décret du 25 mars 1852 :

« On peut gouverner de loin mais on n'administre bien que de près. »

Document n°2 : P. Esplugas, C. Euzet, S. Mouton, J. Viguier, La décentralisation (théorie), in Droit constitutionnel, 5ème édition, Ellipses, 2010 :

[…] LA DEFINITION : La décentralisation est une des techniques d'organisation de l'Etat unitaire comme, par exemple, la déconcentration. La décentralisation implique la création de personnes morales nouvelles dotées d'autonomie. Celles-ci doivent posséder des organes, des compétences et des pouvoirs propres, qui sont prévus par la loi. L'autonomie doit être réelle pour que la décentralisation ne soit pas fictive, mais authentique.

LE PROBLEME : La décentralisation se traduit par certains éléments et on distingue parfois deux types de décentralisation.

1. Les éléments de la décentralisation. La collectivité doit disposer, pour être véritablement décentralisée, d'une autonomie réelle et non pas apparente. En premier lieu, la collectivité décentralisée doit disposer d'organes choisis par ceux qui la composent. Le critère de l'élection est donc fondamental ; c'est l'élection par les membres d'une collectivité qui matérialise le détachement par rap- port à l'Etat. A ce titre, le département avant 1982 n'était

pas authentiquement décentralisé. Dans le même sens, le passage de la région au rang de collectivité locale est lié à l'élection de ses représentants en 1986. En deuxième lieu, la collectivité décentralisée se caractérise par des compétences spécifiques.
Dans l'hypothèse où l'Etat maîtriserait ces compétences, la collectivité ne pourrait pas jouir d'autonomie. Il faut donc une attribution incontestable de domaines d'action particuliers. En troisième lieu, la collectivité décentralisée bénéficie de pouvoirs réels. Elle doit posséder la capacité de décider seule par ses représentants sur ces compétences. Le seul contrôle admis est un contrôle juridictionnel a posteriori et non pas un contrôle a priori comme celui qui existait encore avant 1982.

2. Les deux types de décentralisation. On opposait parfois au milieu du siècle dernier la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle. La décentralisation territoriale se matérialisait par la création de collectivités locales dotées d'une assise territoriales et d'une compétence générale. La décentralisation fonctionnelle out technique ou par services se matérialisait par la création d'établissements publics, sans assise territoriale et avec une compétence spéciale, c'est-à-dire limitée.
Cette pseudo-distinction a été mise à mal depuis trois décennies par plusieurs facteurs. Ainsi la technique de l'établissement public a été utilisée à la place de la collectivité locale, comme les régions, établissements publics dotés d'une compétence plus que spéciale avec la loi du 5 juillet 1972, et collectivités locales dotées d'une compétence moins que générale depuis mars 1986.
La leçon à tirer de ces différents phénomènes, est, finalement que seule la dé- centralisation prenant appui sur le territoire est authentique[...].

Document 3 : Articles 1er, 72, 72-1 et 72-2 de la Constitution de la Vème République :

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

ARTICLE 72-1.

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 72-2.

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Document n°4 : Extrait de l'article « Actualité de la notion de décentralisation » de Florence Chaltiel Terral, Petites affiches, 6 juin 2012, n°113, p.6 :

[...]
La loi de 1884 prévoit plusieurs éléments phares qui demeureront jusqu'en 1982. Elle pré- voit ainsi le principe de l'élection au suffrage universel du conseil municipal qui est désigné pour une durée de quatre ans et est renouvelable intégralement (en 1929, la durée du mandat municipal est portée à six ans). Elle prévoit encore l'élection du maire par le conseil municipal (sauf à Paris), ce qui fait du maire le premier représentant de la commune. Le principe d'unité de l'État se manifeste notamment par la tutelle du préfet, à la fois sur le maire et sur les actes de la commune. C'est aussi dans cette loi que

figure l'attribution d'une clause générale de compétence aux communes, ce qui représente alors une extension significative des attributions des communes. L'article 61 de la loi de 1884 dispose, dans son premier alinéa : « Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ». Cette disposition peut être considérée comme la base de ce qui deviendra sous la Ve République le principe de la libre administration des collectivités locales.

De décentralisations législatives en réformes constitutionnelles augmentant le champ des compétences territoriales, la permanence du pouvoir central est régulièrement ré- affirmée. Elle se manifeste particulièrement à travers les éléments du contrôle de légalité [...] Le contrôle de légalité une constante et une exigence de la décentralisation à la française.

Selon l'article 1er de la Constitution, la République est indivisible. En outre, le principe constitutionnel d'égalité impose que chaque citoyen puisse disposer des mêmes droits sur l'ensemble du territoire. C'est ainsi que la première version de la loi dite acte I de la décentralisation fut d'abord censurée par le Conseil constitutionnel. La cause d'inconstitutionnalité était la décision de rendre exécutoire les actes des collectivités territoriales avant même leur transmission au représentant de l'État. En dépit des approfondissements de la décentralisation, celle-ci s'accompagne toujours d'une déconcentration garantissant l'effectivité d'un contrôle de l'État.

L'article 72, alinéa 6 de la Constitution dispose que dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Ainsi, le principe d'indivisibilité de la République se concilie avec celui de libre administration des collectivités territoriales, à la faveur du contrôle de légalité.

Concrètement, les actes les plus importants des collectivités territoriales doivent donc être soumis au représentant de l'État avant de devenir exécutoire. La réforme majeure introduite par la loi de 1982 est la suppression de la tutelle du représentant de l'État. Ce dernier, en la personne principe du préfet, estimant qu'une décision locale est illégale, peut saisir le juge administratif d'un déféré préfectoral. Seul le juge pourra alors statuer sur la légalité ou non de l'acte, qui sera dès lors, maintenu ou annulé. Il importe de rappeler l'audace du législateur de 1982, audace qui fut censurée par le juge constitutionnel. Les actes des collectivités territoriales devaient en effet être exécutoires avant même la transmission au représentant de l'État. Cette première version fut rejetée par le juge constitutionnel comme atteinte à la fois au principe d'égalité et au principe d'unité de la République. Il n'est pas possible, dans la tradition juridique française de l'État unitaire de laisser s'appliquer des dispositions sans droit de regard de l'État. C'est donc bien une décentralisation à la française qui continue à se construire, comme en témoignent encore les limites de la notion de partenariat entre l'État et les collectivités territoriales […].

Document n°5 : Extraits du manuel « Droit constitutionnel », Dalloz, 19ème édi- tion, 2017 de. Favoreu, P. Gaïa, R Ghevontian, J-L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux, G. Scoffoni :

[...]

LA GARANTIE DE L'AUTONOMIE LOCALE : LE PRINCIPE DE LIBRE AD- MINISTRATION

Un principe à valeur constitutionnelle ¸ mentionné par l'article 34 Constitution. « La loi détermine les principes fondamentaux (...) de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources », ainsi que par l'article 72 Const. « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ».

Le principe de libre administration a été consacré pour la première fois comme principe à valeur constitutionnelle dans une décision n° 79- 104 DC du 23 mai 1979, Territoire de Nouvelle- Calédonie.

Il en résulte que le législateur ne peut y porter atteinte. La libre administration représente donc une liberté constitutionnellement garantie, qui peut être invoquée dans le cadre d'une QPC (Décis. 12–QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque). La jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est at- tachée à préciser les garanties institutionnelles de la libre administration, ainsi que ses moyens et son domaine.

Les garanties institutionnelles de la libre administration : Élection des conseils et représentation par le Sénat :

Le Conseil constitutionnel a été amené à assurer le maintien et à préciser le contenu des garanties institutionnelles prévues par la Constitution, qu'il s'agisse de l'exercice de la libre administration par des conseils élus ou de la représentation des collectivités territoriales par le Sénat. A. L'exercice de la libre administration par les conseils élus 1. Le caractère politique des élections locales Élections locales et libre administration ¸ le critère de la libre administration, expressément énoncé par l'article 72 Constitution, tient dans l'élection des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. C'est le minimum requis pour que la libre administration soit assurée puisque l'élection.

L'exercice de la libre administration par les conseils élus : le caractère politique des élections locales Élections locales et libre administration :

Le critère de la libre administration, expressément énoncé par l'article 72 Constitution, tient dans l'élection des assemblées délibérantes des collectivités territoriales. C'est le minimum requis pour que la libre administration soit assurée puisque l'élection de l'organe exécutif de la collectivité n'est pas exigée par la Constitution de 1958. Depuis la loi du 2 mars 1982, tous les organes des collectivités locales (assemblées délibérantes et organes exécutifs) sont élus, ce qui va donc au-delà des strictes exigences constitutionnelles. La Constitution n'impose pas d'ailleurs, que l'élection ait lieu au suffrage universel direct mais elle interdit évidemment l'institution d'organes délibérants composés en partie de membres élus et en partie de membres nommés. En outre, le Conseil constitutionnel a jugé que « les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage pour la désignation des membres des conseils élus des collectivités territoriales selon une périodicité raisonnable », sans indiquer d'ailleurs de délai précis (Décis. no 93- 331 DC du 13 janv. 1994, Renouvellement triennal des conseillers généraux ; 90- 280 DC du 6 déc. 1990, Concomitance des élections régionales et cantonales). Il en résulte que le législateur ne pourrait pas prolonger de manière excessive le mandat d'élus en cours d'exercice, quel que soit le motif de cette prolongation (M. Verpeaux, 1997). Des élections politiques ◌, alors qu'il était possible de soutenir que les élections locales (municipales, cantonales, régionales) avaient un caractère simplement administratif, à la différence des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales) dont le caractère politique est incontestable, le Conseil constitutionnel a jugé (Décis. no 82- 146 DC du 18 nov. 1982, Quotas par sexe) que les principes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (égalité entre les citoyens) et de l'article 3 de la Constitution (relatifs à la souveraineté nationale et à son exercice, ainsi qu'au droit de suffrage universel, égal et secret) s'appliquaient à tout suffrage poli- tique et notamment à l'élection des conseillers municipaux. Cette qualification de « suffrage poli- tique » vaut évidemment pour toutes les élections locales (cf. Décis. no 98- 407 DC du 14 janv. 1999, Élection des conseils régionaux). Elle est justifiée par le fait que l'électeur y participe en tant que citoyen, membre du corps politique et non en tant qu'individu caractérisé par son appartenance à telle communauté ou collectivité. En outre, les élections locales ne sont pas sans lien avec l'exercice de la souveraineté nationale puisque les membres des as- semblées locales qu'elles désignent participent, dans chaque département, au collège électoral qui élit les sénateurs, ces derniers exprimant la souveraineté nationale. Ce caractère
« politique » des élections locales produit plusieurs conséquences. [...]

Les moyens de la libre administration: Une autonomie de décision relative :

Pour être effective, la libre administration suppose que les collectivités locales puissent disposer d'instruments, tant juridiques que financiers, de nature à leur assurer une certaine autonomie de décision. Celle- ci est limitée par le contrôle administratif exercé par l'État (art. 72 al. 6.) et par la nécessité de maintenir l'unité du pou- voir normatif, conséquence du caractère unitaire de l'État.

Les moyens juridiques : Le pouvoir réglementaire local : Un pouvoir réglementaire habilité

Le principe de libre administration n'implique nullement l'existence d'un pouvoir normatif autonome profit des autorités locales, en dehors du domaine de compétences du législateur. Les compétences réglementaires que ces autorités détiennent, qui leur permettent de prendre des me- sures à portée générale et impersonnelle, leur sont confiées par le législateur. Soit de manière explicite, afin de mettre en œuvre une loi dans un domaine déterminé, soit manière implicite, par l'attribution d'une compétence dont l'exercice implique nécessairement un pouvoir de réglementation (par ex. l'attribution au maire du pouvoir de police administrative). La révision constitutionnelle de 2003 a expressément consacré ce pouvoir réglementaire (Const., art. 72 al. 3 : « Dans les conditions pré- vues par la loi, ces collectivités (...) disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences »). La loi qui confère ainsi une compétence réglementaire à une autorité locale décentralisée n'attribue à cette autorité qu'un moyen indispensable l'exercice de la libre administration. Elle ne conduit pas à lui conférer une partie du pouvoir réglementaire que l'article 21 de la Constitution attribue au Premier ministre. Dans la décision no 2001- 454 DC du 17 janvier 2002 relative à la Corse, Conseil constitutionnel a certes validé la disposition permettant à la collectivité territoriale de Corse de demander à être habilitée par le législateur à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, considérant que principe de libre administration permettait au législateur « de confier à une catégorie de collectivités territoriales le soin de définir, dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, certaines modalités d'application d'une loi » . Encore a- t- il été posé comme limites que cette dévolution du pouvoir réglementaire ne pouvait pas concerner les conditions de mise en œuvre des libertés publiques et qu'elle devait rester dans le cadre des compétences des collectivités territoriales. En outre, elle ne peut se faire que si l'intervention du pouvoir réglementaire national n'est pas prévue. Outre qu'elle a introduit dans l'article 72 Const. la notion de pouvoir réglementaire local, la révision de 2003 a également prévu que les collectivités territoriales (ou leurs groupements) pouvaient être habilitées (par la loi ou le règlement national selon le cas) à déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Ce « droit à l'expérimentation » est encadré par la loi organique du 1er août 2003 et il ne peut en aucun cas aboutir à mettre en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti (Const., art. 72, al. 4).

Un pouvoir réglementaire modulé :

L'étendue du pouvoir réglementaire local peut varier en fonction du degré de précision de la loi d'habilitation et de l'intervention éventuelle du pouvoir réglementaire national. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées (B. Faure, 1996, p. 105). En premier lieu, si la loi investit expressément les autorités décentralisées d'un pouvoir réglementaire, celui- ci peut s'exprimer. C'est ce qu'a admis le Conseil d'État dans les arrêts Préfet de la région Nord- Pas de Calais et Commune de Cuers du 2 décembre 1994 (RFDA 1996. 105) : les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent exercer directement leur pouvoir réglementaire, sans interposition d'un décret du Premier ministre, en fixant la liste des emplois ouvrant droit à un logement de fonction, en application d'une loi du 28 novembre 1990. Encore faut- il souligner que cette loi était suffisamment précise pour s'appliquer directement. En second lieu, il se peut que la loi qui concerne les collectivités locales, habilite de manière très générale le pouvoir réglementaire national pour fixer ses modalités d'appli- cation. Dans ce cas, le règlement national peut apporter à la loi tout complément nécessaire et le pou- voir réglementaire local ne peut, quant à lui s'exprimer que de façon résiduelle. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État dans l'arrêt du 27 novembre 1992, Fédération inter-

communale CFDT et autres (RFDA 1994. 770), à propos d'un décret pris pour définir les régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux sur le fondement d'une habilitation très générale contenue dans la loi du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale. En troisième lieu, la loi peut très bien n'avoir prévu expressément aucune habilitation, ni en faveur du pouvoir réglementaire national, ni en faveur du pouvoir réglementaire local, et n'être pas suffisamment précise pour s'appliquer directement. Dans cette hypothèse les autorités des collectivités locales semblent disposer d'un pouvoir réglementaire « spontané » qui leur permettra de mettre en œuvre la loi (v. CE 13 févr. 1985, Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise, RFDA 1989. 368). Mais un tel pouvoir réglementaire
« spontané » – qu'il trouve sa source dans le principe de libre administration ou tout simplement dans le pouvoir général d'organisation des services de la collectivité – apparaît subsidiaire. En effet, un règlement national (pris sur le fondement de l'art. 21 Const.) peut toujours intervenir : c'est ce qu'a jugé le Conseil d'État dans un arrêt du 1er août 1996 Département de la Loire. À condition toutefois qu'il n'aboutisse pas à créer une « obligation nouvelle » à la charge des collectivités (ou à aggraver une obligation existante). Il résulte en effet, d'une abondante jurisprudence, tant administrative (CE, Ass, 29 avr. 1981, Ordre des architectes, AJDA 1981. 428, note B. Gene- vois) que constitutionnelle (Décis. no 88- 154 L, 10 mars 1988) que seul le législateur est alors compétent pour intervenir dans la mesure où cela touche aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales.

La liberté contractuelle et libre administration :

La liberté contractuelle, dans la mesure où elle constitue un attribut de la libre administration, s'impose au législateur. Celui-ci ne peut y porter atteinte de manière excessive sous peine de mettre en cause, par là même, le principe constitutionnel de libre administration. La protection constitutionnelle. C'est dans la décision no 92- 316 DC du 20 janvier 1993, Prévention de la corruption, que le Conseil constitutionnel a marqué sa volonté de protéger la liberté contractuelle des collectivités locales, en déclarant contraire à la Constitution une disposition de la loi déférée. Celle-ci visait à en- cadrer la liberté des collectivités locales en matière de conventions de délégation de service public (concession, affermage...) et notamment la durée des délégations. Si le Conseil constitutionnel admet le principe de la limitation de cette durée (en vue de renforcer la transparence et la concurrence...) c'est parce que la loi a laissé une marge d'appréciation suffisante aux collectivités concernées pour la négociation des contrats dans chaque cas d'espèce. Mais il juge, en revanche, que le cadre très strict imposé aux collectivités pour prolonger dans certains cas les délégations de service public au- delà de leur durée prévue initialement, constitue « sans justification appropriée, une contrainte excessive qui est de nature à porter atteinte à la libre administration des collectivités locales ». Les collectivités locales doivent donc conserver une liberté d'appréciation et de négociation, cas par cas, pour la conclusion de leurs contrats.

Les moyens financiers Autonomie financière et libre administration :

L'État doit respecter l'autonomie financière des collectivités locales, corollaire de leur libre administration. Celle- ci suppose que les collectivités disposent d'un niveau de ressources suffisant, leur permettant d'exercer pleinement leurs compétences, et qu'elles conservent une marge d'appréciation dans l'utilisation de ces ressources, autrement dit dans la détermination des dépenses. La révision constitutionnelle de 2003 a expressément consacré cette autonomie financière (nouv. art. 72- 2). 1.

Un niveau suffisant de ressources :

C'est au législateur qu'il appartient de déterminer les ressources des collectivités locales (Const., art. 34), qu'il s'agisse de celles transférées par l'État, comme par exemple la dotation globale de fonctionnement (Décis. no 91- 291 DC du 6 mai 1991, Fonds de solidarité des communes) ou même leurs ressources propres. Les collectivités locales ne disposent donc pas d'un véritable

pouvoir fiscal ou d'une véritable autonomie fiscale puisqu'elles ne peuvent ni créer des impôts, ni en déterminer l'assiette ou les modalités de recouvrement (Décis. no 599 DC du 29 déc. 2009, consid. 64). Tout au plus peuvent- elles décider de recourir ou non à un impôt local préalablement autorisé par la loi et d'en fixer les taux dans les conditions déterminées par le législateur (Décis. no 90-277 DC du 25 juill. 1990, Établissement d'impôts directs locaux). Une compétence législative encadrée ¸le très large pouvoir reconnu par la Constitution au législateur en matière de ressources locales n'est cependant pas discrétionnaire. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour effet de restreindre les ressources globales des collectivités locales ou de réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre administration (Décis. no 91298 DC du 24 juill. 1991, Dispositions fiscales rétroactives ; n° 98-405 DC du 29 déc. 1998, Loi de finances rectificative pour 1998 ; no 2000- 432 DC du 12 juill. 2000, Loi de finances rectificative pour 2000). Ainsi, le prélèvement opéré par l'État sur les ressources d'une collectivité au pro- fit d'une autre collectivité ne peut être qu'exceptionnel, ne concerner qu'une partie de l'impôt local et doit être défini avec précision (Décis. no 91- 291 DC, préc.). De même, la suppression d'une ressource fiscale affectée à une collectivité locale n'est tolérée que dans la mesure où elle ne représente qu'une faible perte de recette pour celle- ci (Décis. no 91-298 DC, préc.). Par ailleurs, le législateur ne pourrait pas remettre en cause de manière substantielle les concours financiers de l'État aux collectivités locales sans méconnaître le principe de libre administration (Décis. no 91- 291 DC, préc.). Enfin, une diminution substantielle (de l'ordre d'un sixième) des ressources fiscales, liée à la réforme de la taxe professionnelle, ne porte pas atteinte au principe de libre administration dès lors qu'une compensation intégrale de l'État est prévue (Décis. no 98- 405 DC, préc.). Il en va de même de la suppression de la vignette automobile, perçue par les départements jus- qu'alors (Décis. n° 2000- 242 DC du 28 déc. 2000 ; no 2001- 456 DC du 27 déc. 2001) ou encore de la suppression du droit de licence sur les débits de boisson (Décis. no 2002- 464 DC du 27 déc. 2002). À ce jour aucune loi supprimant ou réduisant une ressource fiscale locale n'a été invalidée.

La part déterminante de ressources propres :

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a prévu quant à elle que « les recettes fis- cales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources », cette règle étant mise en œuvre par une loi organique (LO du 29 juill. 2004). Il s'agissait par là même d'arrêter (ou de freiner) la tendance consistant à sup- primer ou à diminuer les impôts locaux et à les remplacer par des dotations versées par l'État, ce qui réduit la marge de manœuvre des collectivités territoriales. Le ni- veau « déterminant
» de ressources propres (impôts locaux principalement) a été dé- fini par la loi organique comme ne pouvant être inférieur à celui atteint en 2003 (soit 55,97 % pour les communes, 57,40 % pour les départements et 36,07 % pour les régions). La loi organique du 29 juillet 2004 a défini de manière assez large les « ressources propres des collectivités territoriales » en y incluant non seulement les impositions de toute nature dont elles peuvent fixer l'assiette le taux ou le tarif, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d'urbanisme, les produits financiers, les dons et legs, mais encore les impositions dont la loi « dé- termine par collectivité le taux ou une part locale d'assiette ». Ces dernières sont représentées par des impôts nationaux dont la loi prévoit qu'une partie sera affectée aux collectivités territoriales et réparties entre elles selon une clé préétablie et stable, comme par exemple une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée par la loi de finances pour 2004 aux départements afin de com-penser le transfert des charges relatives au revenu minimum d'insertion. Une autre conception, de nature à mieux garantir l'autonomie financière des collectivités territoriales et de ce fait sans doute plus conforme à l'intention du constituant de 2003 aurait consisté à définir les ressources propres uniquement comme celles dont les collectivités territoriales peuvent fixer elles- mêmes le montant, autrement dit celles sur lesquelles elles peuvent exercer leur pouvoir de décision. Toutefois, cette

conception restrictive de la notion de « ressources propres » aurait soulevé des difficultés difficile- ment surmontables : en effet, les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, consubstantiels au mouvement de décentralisation, doivent être compensés financièrement par l'État (Const., art. 72- 2 al. 4), que ce soit par des dotations ou des impôts d'État affectés. Si bien que la part des « ressources propres » aurait à terme cessé d'être « déterminante » si l'on avait retenu une conception stricte de ces dernières, sauf à créer de nouveaux impôts locaux ou à figer les compétences exercées par les collectivités territoriales... Le Conseil constitutionnel pourrait censurer des dispositions législatives portant atteinte au caractère déterminant de la part des ressources propres d'une catégorie de collectivités territoriales mais le contrôle de cette exigence constitutionnelle n'a pas encore débouché à ce jour sur une annulation (Décis. no 2004- 511 DC du 29 déc. 2004 ; no 2005– 530 DC du 29 déc. 2005 ; no 2009– 599 DC du 29 déc. 2009 – remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale).

La compensation financière des transferts, création et extension de compétence :
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités doit s'accompagner de l'attribution des ressources correspondantes aux charges constatées à la date du transfert (Const., art. 72- 2 al. 4 ; Décis. no 2003- 487 DC du 18 déc. 2003 ; no 2003- 89 DC du 29 déc. 2003 ; no 2005- 530 DC du 29 déc. 2005, consid. 90, 93 à 98 ; no 2007- 547 DC du 15 févr. 2007 ; no 2008- 569 DC du 7 août 2008 ; no 2009- 599 DC du 29 déc. 2009). Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation de compensation financière ne s'appliquait pas dans l'hypothèse d'un simple aménagement des conditions d'exercice de la compétence sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi du 22 juillet 1983 (Décis. no 2010- 506 QPC, 18 oct. 2010, consid. 6). S'agissant des créations ou extensions de compétence, l'article 72- 2 Constitution ne vise que celles présentant un caractère obligatoire, le législateur pouvant pour celles-ci évaluer lui- même le ni- veau des ressources supplémentaires attribuées aux collectivités, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration (Décis. no 2004- 509 DC du 13 janv. 2005, Cohésion sociale, consid. 9).

Le principe de péréquation :

Visant à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Const., art. 72- 2, al. 5) ce principe a, quant à lui, été interprété comme n'imposant pas que chaque type de ressources (Décis. no 2003-474 DC du 17 juill. 2003, consid. 18) ou que chaque transfert ou création de compétences (Décis. no 2003- 487 DC du 18 déc. 2003, consid. 18) donne lieu à péréquation. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs admis que pour mettre en œuvre cette péréquation financière entre les collectivités, le législateur puisse regrouper celles- ci par catégories définies par des critères objectifs et rationnels. Il a précisé que cette péréquation peut être destinée à corriger non seule- ment les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges. Elle peut également être mise en œuvre par une dotation de l'État ou encore grâce à un fonds alimenté par des ressources des collectivités territoriales (Dé- cis. no 2009- 599 DC du 29 déc. 2009). [...]

Document n°6 : A. Cabanes, P. Sikorav, « La décentralisation : place à l'acte III scène deux », Le Monde, 5 février 2014 :

En validant l'ensemble de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles – avec une réserve mineure –, le Conseil constitutionnel permet au gouvernement de jouer la deuxième scène de l'acte III de la décentralisation.

La décision du Conseil s'inscrit dans un contexte où de nombreuses propositions ont été formulées concernant la suppression de départements ou de régions et la création de « super métropoles ». L'objectif annoncé par le gouvernement semble être notamment la réduction de la dette publique. Si redéfinir la décentralisation est bien une nécessité dans notre pays encore trop jacobin, présenter

cette réforme comme le moyen de réduire la dette publique confine à la duperie.

Les chiffres de la dette publique française (1.900 milliards d'euros) sont éloquents : 70 % relèvent de l'Etat, 7 % des collectivités locales. La part de l'Etat dans la dette publique française a augmenté presque continuellement depuis 1978, tandis que la part des collectivités locales est demeurée stable, voire en légère diminution. Les dépenses des collectivités locales de 1983 à 2011 – hors transferts additionnels de compétences – sont restées inférieures à la progression du PIB.

S'agissant de la réduction de la dette publique, l'Etat doit montrer l'exemple, tant par l'adoption de mesures symboliques (la suppression d'institutions moins faites pour être utiles aux citoyens que pour remercier les bons et loyaux services rendus aux pouvoirs politiques successifs) que par une réforme de fond de l'organisation administrative de l'Etat. Si le prisme de la réduction de la dette publique n'est pas pertinent, comment aborder le nécessaire renouvellement de la décentralisation dont l'organisation initiale remontre à 1982 ? La décentralisation consiste à déterminer le niveau de relation appropriée entre les citoyens et leurs élus locaux, fondée sur le principe constitutionnel de subsidiarité, qui énonce que les collectivités locales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Premier objectif : ne pas focaliser le débat sur la suppression des régions ou des départements. Les créations de « super-métropoles » ou de « super-régions » s'inscrivent en contradiction avec l'objectif même de la décentralisation, l'échelon régional étant le plus éloigné des citoyens. Or, le principe de subsidiarité exige le maintien d'un lien de proximité entre les citoyens et leurs collectivités, notamment les départements et les communes, auxquels les Français sont très attachés. Inciter au regroupement de départements ruraux dans des zones déshéritées mutualiserait cependant les efforts réalisés pour maintenir un niveau d'infrastructures et de services homogènes sur le territoire national.

Deuxième objectif : réduire le nombre de communes. En 2013, le nombre de communes était encore de 36 681, dont plus de 86 % ont moins de 2 000 habitants. La réduction drastique du nombre de nos communes doit constituer la priorité politique absolue en matière de décentralisation.

Troisième objectif : simplifier l'enchevêtrement des compétences des collectivités qui sont fréquemment en concurrence les unes avec les autres. Or, la loi validée par le Conseil constitutionnel renoue avec le principe de la clause de compétence générale, dont l'abandon avait pourtant été voté en décembre 2010. Le surcoût de cet enchevêtrement représente presque 11 milliards d'euros pour les départements ; 7 milliards d'euros pour les régions. La création de « super-métropoles » mérite sans aucun doute d'être envisagée. En revanche, si - comme à Paris -, le projet de métropole vient s'ajouter à la Société du Grand Paris, au STIF, aux compétences de RFF, de la SNCF et de la RATP, la simplification annoncée comme objectif risque de ne pas être at- teinte.

Quatrième objectif : éviter une approche autoritaire dans le regroupement des collectivités. Abandonner toute consultation des citoyens peut être tentant, mais risque d'accentuer la défiance vis-à-vis du politique. La décentralisation ne peut pas progresser en donnant l'impression d'une moindre démocratie locale directe. Prochaine étape en avril avec la présentation d'une deuxième loi de dé- centralisation en conseil des ministres ; les écueils à éviter restent nombreux avant de pouvoir fédérer les citoyens autour d'un scénario consensuel.

Document n°7 : J. Demarthon, « La loi NOTRe pour les collectivités territoriales définitive- ment adoptée », Le Monde, 16 juillet 2015 :

Le texte confirme la montée en puissance des régions et des intercommunalités, mais sans que cela se fasse au détriment des départements, comme envisagé au départ. Après un périple parlementaire de deux ans, le Parlement a adopté définitivement, jeudi 16 juillet, le projet de loi sur la répartition des compétences entre collectivités. Le Sénat a en effet approuvé dans l'après-midi le texte voté dans les mêmes termes au cours de la matinée à l'Assemblée nationale. Troisième volet de la

réforme territoriale, le projet de loi NOTRe (pour « Nouvelle organisation territoriale de la République ») a été voté par 259 sénateurs, 49 s'étant prononcés contre. Le texte confirme la montée en puissance des régions et des intercommunalités, mais sans que cela se fasse au détriment des départements, comme envisagé au départ. Il confie aux régions l'économie et les grandes orientations stratégiques, aux
départements la solidarité, et au bloc communal les services de proximité.

❖ Concernant les régions et les départements :

– La clause de compétence générale, qui permet à une collectivité territoriale de se saisir de tout sujet ne relevant pas de l'Etat, est supprimée pour les départements et régions. Elle avait déjà été abrogée pour ces collectivités sous le mandat de Nicolas Sarkozy mais rétablie au début de celui de François Hollande.

– Les treize grandes régions créées en métropole par la loi votée en décembre 2014 auront compétence sur le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées et les transports, y compris les transports scolaires. Elles pourront jouer un rôle de coordination en matière d'emploi, mais sans toucher aux prérogatives du Pôle emploi, et auront un rôle moteur en matière d'environnement.

– Les départements, dont le projet de loi initial prévoyait la suppression, sont préservés et gardent la gestion des collèges, des routes et de l'action sociale.

– La culture, les sports, le tourisme, l'éducation populaire et les langues régionales relèveront à la fois des régions et des départements. Les ports pourront relever, selon les cas, d'un type ou d'un autre de collectivité territoriale.

er – Les
deux départements et la région de Corse fusionneront à compter du 1 janvier 2018 dans une collectivité unique.

❖ Concernant les communes, les intercommunalités et les métropoles :

– Les intercommunalités devront être d'une taille minimale, fixée à 15 000 habitants, sauf exceptions (notamment en zone de montagne).

– Elles seront obligatoirement chargées de la collecte et du traitement des déchets, de la promotion touristique, des aires d'accueil des gens du voyage, et, à partir de 2020, de l'eau et de l'assainissement. Les autres compétences se répartiront avec les communes.

– La métropole du Grand Paris (MGP), créée comme les autres métropoles par la loi votée en 2014, verra formellement le jour comme prévu au 1er janvier 2016, mais ne se verra attribuer l'essentiel de ses compétences qu'un an plus tard, début 2017.

– Les représentants de Paris au conseil de la MGP ne seront pas désignés par le Conseil de Paris, comme initialement prévu, mais par chaque conseil d'arrondisse- ment, ce qui aura pour effet d'empêcher l'élection de Nathalie Kosciusko-Morizet, chef de file de la droite dans la capitale.

Document n°8 : Extraits M. Verpeaux, « La loi NOTRe dans son contexte », RFDA , 2016 :

[…]

La difficile régionalisation à la française

C'est la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui a fait entrer les régions dans la liste des collectivités territoriales de l'article 72, alinéa 1er, de la Constitution. Ni du point de vue des institutions ni de celui de leurs compétences, néanmoins, cette révision n'apporta une innovation pour les régions, en dehors de la reconnaissance de leur existence. Pour le constituant de 2003, comme, avant elle, pour la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la région était une collectivité territoriale comme les autres et aucune raison ne justifiait de la traiter différemment. Mieux même, la constitutionnalisation de la région n'a fait qu'accentuer la similitude de la région avec les autres collectivités de droit commun, qui étaient déjà présentes dans la Constitution. La révision de 2003 fut peut-être l'occasion manquée de faire des régions des collectivités bénéficiant d'une reconnaissance particulière. Les réformes entreprises en 2015, et notamment la loi NOTRe, ont cherché à donner une place particulière à des régions redéfinies dans le paysage territorial français.

Les nouvelles régions

C'est avec l'argument de donner aux régions françaises une dimension européenne que le législateur est venu délimiter les nouvelles régions par la loi du 16 janvier 2015 précitée. Il fallait constituer, pour défendre le principe de la loi, de « grandes régions » à l'instar de celles qui existeraient dans d'autres pays. La pertinence de la comparaison reste à démontrer, et l'argument illustre une confusion, souvent répandue, entre la taille, les compétences et les moyens reconnus aux régions ou autres échelons sub-étatiques dans les pays considérés. En réalité, il n'existe aucun modèle européen et les régions ou autres niveaux de cet ordre, comme les Länder allemands, les régions italiennes ou les communautés autonomes espagnoles n'ont pas tous une taille supérieure à celle des régions françaises.

Avant la loi de 2015, les régions existaient dans leurs limites établies par le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (12). C'est dans ces cadres territoriaux que la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions avait institué les régions sous la forme d'établissements publics et que la loi précitée du 2 mars 1982 les a consacrées sous le statut de collectivités territoriales. L'alinéa 2 de l'article L. 4111-1 CGCT, applicable jusqu'au 31 décembre 2015, disposait, dans cette « ancienne » version, que les régions « sont créées dans les limites territoriales précédemment reconnues aux établissements publics régionaux ».

C'est cette carte, qui avait réussi malgré tout à développer une certaine forme d'identité régionale, y compris dans des régions où celle-ci n'était pas évidente comme en Champagne-Ardenne ou en Rhône-Alpes, qui fut révisée par la loi du 16 janvier 2015. Cette loi, préparée à la hâte, sans consultation des conseils régionaux et encore moins des électeurs, a dressé une carte de douze régions métropolitaines. Ce chiffre de douze régions ne tient pas compte de la Corse, devenue collectivité territoriale de la République depuis 1991(13) et qui, sauf modification législative, deviendra une collectivité territoriale unique au 1er janvier 2018 par décision de la loi du 7 août 2015 (art. 30 de la loi). [...]

Les compétences régionales :

On ne trouve pas, dans le cadre du titre XII, de références spécifiques aux compétences des régions, en dehors de leur consécration à l'alinéa 1er de l'article 72. Les difficultés récurrentes pour leur attribuer des compétences élargies, notamment par rapport aux départements, posent la

question de l'absence de place privilégiée reconnue aux régions par rapport aux autres niveaux territoriaux. Une forme de primauté ou de prééminence pourrait être justifiée, ne serait-ce que parce qu'elles recouvrent un territoire plus grand qui englobe nécessairement celui des autres collectivités, à défaut d'une légitimité historique ou politique plus ancienne.

La confrontation permanente avec les départements est illustrée de manière significative à propos de la répartition de leurs compétences respectives. Un lent mouvement de bascule s'est néanmoins opéré, à compter de la création des régions en tant qu'établissements publics par la loi du 5 juillet 1972 jusqu'à la loi NOTRe du 7 août 2015. Au départ cantonnées dans un rôle de distributeurs de crédits publics d'investissement, les régions ont acquis par étapes des compétences nouvelles en qualité de collectivités territoriales de plein exercice, et parfois au détriment des départements. Ces compétences étaient néanmoins ciblées sur l'économie et l'aménagement du territoire comme le montrait d'emblée la loi du 7 janvier 1983. A plusieurs reprises, les régions ont manqué l'occasion de connaître une réforme de grande ampleur qui leur aurait attribué l'essentiel des compétences locales, en dehors de celles de proximité qui ne peuvent être raisonnablement confiés qu'à l'échelon communal et désormais intercommunal. Ce fut le cas lors de la loi du 13 août 2004, qui devait consacrer de nouvelles et importantes compétences au profit des régions, et qui a surtout bénéficié aux départements. Les compétences, qui devaient être clarifiées au titre de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, n'ont pas eu le temps de l'être, du fait des élections de 2012.

Quant aux lois promulguées après cette alternance politique, elles n'ont pas non plus réalisé de grands progrès dans la reconnaissance de compétences spécifiques pour les régions. Cette question est liée à ce qui peut être qualifié de feuilleton de la « clause de compétence générale ». Celle-ci avait été supprimée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyant que, à l'horizon du 1er janvier 2015, le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région mais « dans les domaines de compétence que la loi lui attribue » (art. L. 4221-1 modifié par l'art. 73 de la loi). Elle avait été rétablie par la loi MAPAM du 27 janvier 2014 qui avait abrogé la référence aux « domaines de compétence », mais au même titre et dans les mêmes conditions que pour les départements et dans un chapitre intitulé « Le rétablissement de la clause de compétence générale ». De manière un peu chaotique, la clause de compétence générale a été de nouveau supprimée par la loi NOTRe, cette fois en séparant, au moins formellement, les dispositions applicables aux régions et celles intéressant les départements. C'est ainsi que l'article 1er de la loi rétablit la rédaction de l'article
L. 4211-1 issue de la loi de 2010, selon laquelle « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue », alors que c'est l'article 94 de la loi NOTRe qui procède à la même modification de l'article L.3211-1 pour les départements dans un chapitre 1er du Titre III, sous le titre « Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d'intervention pour les solidarités territoriales et humaines » [...]

La délicate recomposition territoriale française infra-régionale :

Si la carte des régions a connu des évolutions par la loi du 16 janvier 2015, la question de la suppression ou de l'évolution des départements n'a pas constitué l'objet de ce texte. Elle ne figure pas non plus au centre de la loi NOTRe, au moins de manière expresse.

Outre le fait que la création de grandes régions pourra être l'occasion, involontaire, de renforcer l'échelon intermédiaire afin de renforcer dans l'avenir, la proximité, la sup- pression pure et simple des départements s'est vite avérée impossible pour des raisons constitutionnelles, les départements étant inscrits dans la liste des collectivités territoriales à l'article 72, alinéa 1er. Ensuite, la question des compétences exercées par les départements restait posée, avec, comme corollaire, celle de savoir à quel autre échelon elles pouvaient être confiées. Cette résistance a été alors double. Les départements ont su protéger leur existence et ils ont su maintenir leurs compétences, du moins

certaines d'entre elles [...]

Le choix incertain entre les communes et les intercommunalités

La loi NOTRe se trouve aussi au cœur de la réflexion sur l'avenir des communes françaises. Un phénomène nouveau s'est en effet produit au 1er janvier 2016, celui de la réduction du nombre de communes en France. Pour la première fois depuis des décennies, le nombre de communes a diminué de manière significative, puisqu'il a été réduit de 773 unités. En effet, 317 communes nouvelles ont été créées à cette date, qui regroupent 1 090 communes. La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a en effet établi une procédure de regroupement, aboutissant à la création de communes nouvelles, en évitant le mot de « fusion » apparue dans la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes. La loi de 2010 semblait néanmoins ne pas tenir compte de manière satisfaisante des anciennes communes et, de manière encore plus sensible, des élus des communes acceptant de fusionner. La loi 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (sic), vise ainsi à faciliter la création et le fonctionnement des communes nouvelles. Pour ce faire, elle a mis en place des incitations financières temporaires afin de favoriser la création de communes er nouvelles avant le 1 janvier 2016. Pour l'essentiel, elle a cherché à maintenir, autant que faire se peut, l'existence des anciennes communes au sein des communes nouvelles sous la forme de communes déléguées (CGCT, art. L. 2113-1 et s.). Cette législation, si ses effets quantitatifs devaient se pour- suivre, est de nature à envisager une restructuration sérieuse du paysage communal, même si la solution française, consistant à favoriser ces regroupements par des incitations financières est une source d'inquiétudes pour le budget de l'État (art. 13 à 15 de la loi du 16 mars 2015).

L'autre piste explorée par le législateur pour tenter de résoudre la question du nombre de communes en France, qui est aussi celle de leur faiblesse, du fait d'une population trop faible, synonyme de moyens aussi insuffisants, est celle de l'intercommunalité. Depuis les années 1990 et les deux lois, celle d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République (art. 71 et s.) et celle n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopé- ration intercommunale du 12 juillet 1999, considérées comme le véritable acte II des lois de décentralisation, le législateur a voulu rationaliser et achever l'intercommunalité. Tel était l'objectif de la loi du 16 décembre 2010 et celui-ci a été approfondi par la loi NOTRe dans un titre II intitulé « Des intercommunalités renforcées ». L'un des moyens pour y parvenir consiste en la création d'intercommunalités de grande taille (art. 33 de la loi modifiant l'art. L. 5210-1-1). La loi du 7 août 2015 a fixé ainsi un seuil démographique de 15 000 habitants, assorti de nombreuses exceptions, aboutissant à ce que les élus appellent des « communautés XXL », ce qui ne va sans poser de grandes difficultés dans les relations entre les communes [...].

Document n°10 : Extrait A. Duranthon, « La subsidiarité et collectivités territoriales », thèse, 2015 :

[...]

Victimes collatérales inévitables de l'effort unificateur de la Révolution française, les collectivités territoriales se sont vues réduites à des échelons administratifs par l'effort d'objectivation de leur structure consécutive à l'instauration de la République et du modèle de l'État unitaire. À l'heure où la République est durablement assise et où le modèle de l'État unitaire consent à laisser davantage de place à un pluralisme qui n'est plus articulé autour de la contestation de son monopole souverain, les collectivités bénéficient, par un effort de décentralisation constant depuis la fin du XIX siècle, d'une considération renouvelée. Par petites touches législatives, jurisprudentielles et

désormais constitutionnelles, les collectivités se voient garantir, au sein de l'État uni- taire, une marge de manœuvre qui correspond à l'instauration d'une logique de subsidiarité. Si la formulation de l'article 72 alinéa 2 ne contient pas, de façon explicite, les conditions d'un principe de subsidiarité abouti, elle contient néanmoins en son sein les conditions de l'affirmation d'une logique subsidiaire.

Un nouveau rapport à la décentralisation se structure ainsi peu à peu. Là où le mouvement était initialement pensé comme un mouvement décentralisateur, c'est-àdire visant à ce que l'État souverain consente à l'exercice par les collectivités de certaines compétences dont il est pensé comme le seul titulaire naturel, le résultat produit est inverse. Sur tout le territoire, les collectivités se saisissent de compétences facultatives au nom de leur intérêt public local et construisent un nouveau versant de l'action publique entièrement indépendant de l'État du point de vue des compétences. Répondant aux besoins locaux qu'elles identifient, elles s'assurent que l'intérêt général local soit, à travers leur action, satisfait, le tout sous la forme de cercles concentriques qui, parfois, se recoupent et se complètent. La construction de l'action publique, traditionnellement descendante, se trouve ainsi complétée par un mouvement ascendant qui, par un jeu d'équilibre, cohabite avec le jeu descendant de règles restrictives provenant du législateur et visant à permettre la cohabitation entre un fondement général à la compétence des collectivités et la satisfaction d'objectifs de rationalisation, de réorganisation et d'économies propres à l'État [...].